

刑法
No391

共通問題 H29-6

(配点: 2)

月 日

月 日

わいせつ物頒布等の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、甲に()内の罪が成立しないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. インターネットを介した書籍販売業を営む甲は、日本語で書かれたわいせつな文書である小説を、その購入を申し込んできた日本国内在住の多数の外国人に販売したところ、いずれの外国人も日本語の読解能力に乏しく、同小説の内容を理解できなかった。(わいせつ物頒布罪)

イ. 甲は、インターネットを介して多数の希望者を募った上、その希望者らに無料で交付する目的で、わいせつな映像を記録したDVDを所持した。(わいせつ物有償頒布目的所持罪)

ウ. 甲は、わいせつな映像を記録したDVDの販売業者に対してそのDVDの購入を申し込み、これを購入した。(わいせつ物頒布罪の教唆犯)

エ. DVDのレンタル業を営む甲は、わいせつな映像を記録したDVDを、多数の顧客へ有償で貸し出した。(わいせつ物頒布罪)

オ. 甲がインターネットを介したわいせつな映像の販売業を営み始めたところ、その購入を申し込んできた顧客は1名だけであったが、甲は、その者に対して、電子メールに同映像のデータを添付して送信した。(わいせつ物頒布罪)

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No391

わいせつ物頒布等の罪

共通H29-6

正解

3

正答率

81%

ア 成立する

最判昭48.4.12は、「文書の猥褻性の有無はその文書自体について客観的に判断すべきものであり、現実の購読層の状況あるいは著者や出版社としての著述、出版意図など当該文書外に存する事実関係は、文書の猥褻性の判断の基準外に置かれるべきである」としている。したがって、本記述では、外国人が読解能力に乏しく小説の内容を理解できなかったとしても、甲は客観的に「わいせつな文書」である小説を「頒布」した以上、わいせつ物頒布罪が成立する。

イ 成立しない

175条2項のわいせつ物有償頒布目的所持罪は、「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した」者について成立する目的犯である。したがって、甲はインターネットを介して多数の希望者を募った上、その希望者らに無料で交付する目的しかなかったのであるから、「有償で頒布する目的」を欠き、わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。

ウ 成立しない

わいせつ物頒布罪（175条1項）において、頒布の相手方は必要的共犯となるが、これを処罰する規定がない以上、頒布罪の共犯として教唆や幫助が処罰されることはない。その実質的理由として、わいせつ物を積極的に伝播する行為は当罰的な違法性を備えているが、相手方として伝播を可能にするにとどまる行為については当罰性が低いという考慮も援用されるべきとする見解もある。よって、DVD販売業者にわいせつ物頒布罪（175条1項）が成立するとしても、DVDの購入を申し込んだ甲の行為について、わいせつ物頒布罪の教唆犯（61条1項・175条1項）は成立しない。

エ 成立する

「頒布」（175条1項）とは、不特定又は多数の者に有償又は無償で交付することをいう。不特定又は多数の者に対する有償貸与は「頒布」に含まれる。わいせつな映像を記録したDVDを多数の顧客へ有償で貸し出した甲の行為は175条1項前段の「頒布」に該当し、わいせつ物頒布罪が成立する。

オ 成立する

175条1項における「頒布」とは、不特定又は多数の者に有償又は無償で交付することをいう。すなわち、不特定かつ多数の場合のみでなく、不特定かつ少数の場合又は特定かつ多数の場合も、「頒布」に該当するとされている。そして、たまたま1名の顧客に交付・譲渡等したに過ぎない場合であっても、それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば、頒布に該当するとされている（大判大6.5.19）。したがって、わいせつ映像の購入を申し込んできた顧客は1名だけであっても、わいせつな映像の販売業を営み始め、同映像を電子メールにて添付し送信する甲の行為は「頒布」に該当するため、わいせつ物頒布罪が成立する。

以上により、（ ）内の犯罪が成立しないのは、イとウであり、したがって、正解は肢3となる。